

1500104-21.2022.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Letícia Pozzi Buassi

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/11/2022

... de evidenciar terem os acusados praticado o tráfico ilícito.

Contudo, aponta a Jurisprudência dos Tribunais não ser necessária a prova efetiva do tráfico para a formação do Juízo de certeza, bastando a comprovação pelos elementos que cercam o agente. Confira-se: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

4ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500104-21.2022.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500104-21.2022.8.26.0559

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WENDEL ALESSANDRO DE CAMARGO SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. Maria Letícia Pozzi Buassi

Vistos.

WALLYSON CRISTHIAN CASTRO DA SILVA e WENDEL ALESSANDRO DE CAMARGO SILVA, qualificado nos autos, foram denunciados como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c. c. o art. 61, inc. II, "j", do Cód. Penal, porque no dia 12 de janeiro de 2022, por volta das 13h, sob o viaduto "Jordão Reis", nesta cidade e comarca, traziam com eles, para futura entrega a terceiros, duas porções de "maconha", pesando 27g e treze porções de cocaína na forma de "crack", pesando 7,1g, substâncias estas entorpecentes e determinantes de dependência física e psíquica, o que faziam sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Portavam, ainda, os réus, uma bolsa, dois aparelhos celulares e R\$ 708,00.

Policiais militares, com informações de populares sobre a prática do comércio ilícito, perseguiram e abordaram os réus, que dispensaram uma sacola contendo uma porção de "maconha" e tentaram fugir ao notar a viatura.

Nas vestes de Wallyson, localizou-se um aparelho celular e R\$ 95,00. Em revista pessoal a Wendel, os agentes encontraram um aparelho celular, o restante das drogas e R\$ 613,00.

Oferecida a denúncia foram os réus notificados e apresentaram defesa prévia. Recebida a denúncia designou-se audiência de instrução, na qual foram ouvidas duas testemunhas comuns.

Após, foram interrogados os réus.

Em debate, o representante do Ministério Público, sustentando demonstradas a materialidade dos fatos e a autoria do delito, requereu a condenação dos acusados nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, pleiteou, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da abordagem policial. No mérito, pugnou pela absolvição dos réus apontando, em suma, insuficiência de provas a delinear o crime e, sucessivamente, a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei em tela, a aplicação da figura do tráfico privilegiado e a fixação da pena no mínimo legal.

É o relatório.

DECIDO.

Por primeiro, não há nulidade na abordagem policial, tampouco qualquer indicativo de abuso de autoridade, por parte dos agentes.

Isso porque, é dever da polícia ostensiva, com base em protocolos pré-existentes e de rígida elaboração, fundados, inclusive, na experiência pessoal, averiguar situações de desrespeito à ordem jurídica e social.

Ademais, in casu, não se observa qualquer indicação de violação de direitos dos réus, que dispensaram o tóxico e tentaram fugir, motivando a revista pessoal e o desfecho da diligência policial, a qual, registre-se, obedeceu às normas legais pertinentes.

Afastada a preliminar, passo à análise do mérito.

A materialidade dos fatos vem comprovada por intermédio do auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, que revela o encontro dos entorpecentes, do dinheiro e dos aparelhos celulares em tela.

Há, ainda, o laudo de constatação de fls. 43/49 e o laudo de exame químico toxicológico de fls. 87/89, concludentes no sentido de se tratar de Tetrahydrocannabinol – THC e de cocaína, as substâncias encontradas.

A perícia efetivada nos aparelhos celulares apontou diálogos relativos à prática do comércio ilícito (fls. 167/179).

Na fase policial, ambos os réus asseguraram destinar-se o entorpecente ao consumo próprio.

Em Juízo, assegurou Wallyson ser o possuidor da droga, que no local vendia, tendo o corréu entregue, a título de pagamento, R\$20,00 pela “maconha” adquirida, o que foi confirmado por Wendel, em audiência.

Certo é terem os réus, de forma combinada, modificado a versão anteriormente narrada, na tentativa de afastar a responsabilidade penal por parte do réu Wendel, detido. Contudo, a versão combinada destoa de todo o conjunto probatório.

Contam os policiais terem informações de populares propiciado a perseguição e a abordagem aos réus, que dispensaram uma sacola contendo uma porção de “maconha”, na via, e tentaram fugir ao perceber a viatura. Detalharam o encontro, nas vestes de Wallyson, do aparelho celular e de R\$ 95,00, bem como, em revista pessoal a Wendel, do celular, do restante das drogas e de R\$ 613,00.

Vale lembrar que o fato de policiais que participam de diligências serem testemunhas sobre estas, torna o relato apresentado mais rico em detalhes e, por isso, mais digno de fé.

No caso em tela as declarações apresentaram-se de forma harmônica e coesa com o restante da prova, razão pela qual não podem ser desconsideradas, inexistindo qualquer motivo para que quisessem os policiais militares incriminar os réus ou forjar o crime.

A jurisprudência é uníssona ao reconhecer a validade das declarações prestadas, em juízo, por policiais. Neste sentido o Supremo Tribunal Federal: “o valor do depoimento pessoal dos servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que

esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (HC 73.518/SP, rel. Min. Celso de Mello, DJe 14.03.2011).

Urge consignar ser grande a quantidade de droga apreendida em comparação à condição financeira dos réus, que não comprovaram relação de emprego, logo, seria imprópria somente a eventual uso, sendo a negociação, guarda ou transporte dos produtos, medida impositiva, na situação.

Como não se produziu prova a contrariar o já citado auto de exibição e apreensão, o tráfico é consequência lógica das provas colhidas.

Dessa forma, verifica-se não existirem apenas indícios de prova, mas sim clareza e harmonia entre elas, no sentido de evidenciar terem os acusados praticado o tráfico ilícito.

Contudo, aponta a Jurisprudência dos Tribunais não ser necessária a prova efetiva do tráfico para a formação do Juízo de certeza, bastando a comprovação pelos elementos que cercam o agente. Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 4. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático probatório amalhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos. 5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. 6. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente” –, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso” (STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

Importa registrar que eventual dificuldade financeira não autorizaria, de forma alguma, a prática criminosa. Até porque, se assim não fosse, desnecessária seria a existência de normas legais, reguladoras do comportamento humano.

Além disso, destaca-se não ter a defesa delineado, de forma cristalina, a apresentação, por agentes, de tóxico não achado na posse dos réus, e nem motivo haveria para tanto. Por isso, tal versão é indigna de crédito.

Por fim, vale observar que as finalidades da agravante prevista no art. 61, inc. II, “j”, do Cód. Penal, são a proteção da sociedade, bem como punição mais rigorosa da conduta de quem, valendo-se das facilidades do contexto calamitoso, pratica delitos.

In casu, não havendo nexos causal entre a situação de pandemia e a conduta dos réus, é de rigor o afastamento da mencionada agravante. Nesse sentido: “Primeiramente, faz-se necessário afastar a aplicação da agravante do art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, pois não restou devidamente comprovado nos autos que o réu se aproveitou das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pelo estado de calamidade pública decretado em virtude da pandemia do COVID-19.” (TJSP, 1ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 1512067-20.2020.8.26.0228, Rel. Andrade Sampaio, 12.02.2021).

Convencida da responsabilidade penal dos réus, passo a individualizar as penas.

-WALLYSON CRISTHIAN CASTRO DA SILVA

Tendo em vista os elementos norteadores do art. 59 do Cód. Penal, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por não

apresentar maus antecedentes.

Deixo de aplicar a menoridade do acusado e a confissão da autoria, circunstâncias atenuantes contidas no art. 65, incs. I e III, "d", do Cód. Penal por já ter fixado a pena-base no mínimo legal.

-WENDEL ALESSANDRO DE CAMARGO SILVA

Tendo em vista os elementos norteadores do art. 59 do Cód. Penal, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por não apresentar maus antecedentes.

Verificada a reincidência (fls. 50/55), incide a circunstância agravante prevista no art. 61, inc. I, do Cód. Penal, que se compensa com a menoridade do acusado, circunstância atenuante contida no art. 65, inc. I, do Cód. Penal, permanecendo inalterada a pena.

O regime inicial de cumprimento da pena, para ambos os réus, é o fechado (art. 1º, § 1º, da Lei n.º 11.464/07).

Destaco que quando da fixação do regime inicial de cumprimento da pena, já se observou o período de prisão provisória, nos termos do § 2º do art. 387 do Cód. de Proc. Penal.

O fato de ter o réu Wendel respondido encarcerado à instrução do feito não implica, com a prolação desta sentença, na concessão de regime menos gravoso. Neste sentido:

"(...) PENA. DETRAÇÃO. CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - ART. 387, § 2º, DO CPP, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 12.736/12. FIXAÇÃO A SER EFETUADA PONDERANDO-SE CONJUNTAMENTE O QUANTUM DA PENA APLICADA COM AS CONDIÇÕES SUBJETIVAS PREVISTAS NOS ARTS. 33, § 3º E 59 DO CP. ENTENDIMENTO. O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2º, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3º, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal. A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença". (TJSP, Apelação Criminal nº 1500199-27.2019.8.26.0407, Rel. Des. Grassi Neto, 9ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 19/11/2020). Ainda: "Descabe, igualmente, pleitear aqui regime prisional mais brando com base na atual redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, o que ora se destaca, quer à luz do invocado princípio da suficiência da sanção, quer porque a consideração do tempo de prisão provisória não prescindiria de demonstração cabal de bom comportamento carcerário e de condições subjetivas favoráveis, tal como se exige para a avaliação do cabimento de progressão. Se assim não fosse, ficaria ferida de morte a lógica do sistema penal. E tal demonstração não existe nos autos." (TJSP, Apelação Criminal nº 1500128-92.2021.8.26.0559, Rel. Fátima Gomes, 9ª Câmara de direito Criminal, julgado em 31.03.2022).

Deixo de aplicar o § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, ante a reincidência do réu Wendel e a personalidade voltada à prática criminosa de Wallyson, conforme diversos apontamentos de atos infracionais na certidão de fls. 56/60.

Neste sentido: "(...) Não há como ser aplicada a minorante prevista no § 4º do art. da Lei de Drogas em favor do recorrente, haja vista a vedação legal expressa da concessão dessa benesse aos acusados reincidentes. O reconhecimento da agravante da reincidência, na segunda etapa da dosimetria, não é incompatível com a sua utilização, na terceira fase, para afastar a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porquanto o referido

instituto jurídico é sopesado com finalidades distintas em cada fase de fixação da pena, justamente para se alcançar a justa e correta reprimenda necessária para a reprovação e prevenção do delito perpetrado. Não há falar, portanto, em bis in idem. Precedentes.” (STJ, HC 671329/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 15.06.2021).

O valor unitário do dia-multa é o mínimo legal, considerada a situação econômica do acusado (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06).

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e condeno WALLYSON CRISTHIAN CASTRO DA SILVA, R.G. nº 60.864.956 e WENDEL ALESSANDRO DE CAMARGO SILVA, R.G. nº 58.357.509, cada um, a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa, por terem infringido o art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Não poderá o réu Wendel apelar desta sentença em liberdade, nos moldes do art. 1º, § 3º, da Lei nº 11.464/07.

Ainda que assim não fosse, em sendo necessária a prisão no correr da instrução do feito, a prolação desta sentença condenatória apenas reforça os motivos ensejadores do afastamento do réu Wendel do convívio social, por garantia da ordem pública. Recomende-se o réu Wendel no presídio onde se encontra, expedindo-se mandado de prisão, se necessário.

Porque aguardou o réu Wallyson a instrução do feito em liberdade, faculto eventual apelação nessa mesma condição, devendo observar as medidas cautelares fixadas às fls. 138.

A pena pecuniária será atualizada a partir da data do fato, uma vez que a correção monetária não apresenta nenhum plus, mas sim tentativa de reposição do poder aquisitivo da moeda.

Força concluir ainda, que a multa não corrigida perde o caráter aflitivo, tornando inútil a imposição, inatendidas as finalidades da sanção penal de punição, dissuasão e reeducação do delinquente.

Observados o art. 63 da Lei nº 11.343/06 e o art. 91, inc. II, “b”, do Cód. Penal, DETERMINO O PERDIMENTO do celular e do dinheiro (fls. 09/10), pois obtidos em razão do comércio ilícito, conforme prova colhida. Para tanto, oficie-se ao FUNAD.

Após o trânsito em julgado, nos termos do art. 72 da Lei nº 11.343/06, oficie-se à Autoridade Policial para o fim de destruição das amostras de entorpecente guardadas para contraprova.

Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

P.R.I.C.

São José do Rio Preto, 31 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA